

1501196-34.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente. Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP 15130-000, Fone: (17)

3242-3001, Mirassol-SP - E-mail: mirassol2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501196-34.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187203/2022 - 01º D.P. MIRASSOL, 26064283 - 01º D.P.

MIRASSOL, 2187203 - 01º D.P. MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ELIAS BARBOZA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 08 de novembro de 2022, às 15:00h, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ANDRÉ DA FONSECA TAVARES, Juiz titular da 2ª Vara da Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, comigo Escrevente ao final nomeada, estando presentes também, o DD. Promotor de Justiça, Dr. VALMOR DE MATTOS JÚNIOR; o réu RODRIGO ELIAS BARBOZA, seu defensor, Dr. MATHEUS VECCHI; as testemunhas arroladas pela acusação, Marcelo Augusto Lourenço, Rodrigo Vinicius Salles e a testemunha arrolada pela defesa, Marcelino Ramos Silva. Abertos os trabalhos, pelo MM. Juiz de Direito foi oportunizado ao réu exercer seu direito de entrevista prévia com seu Defensor de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP, o que por eles foi dispensado. Em seguida, pelo MM. Juiz foram colhidos depoimentos das testemunhas e interrogado o réu, pelo sistema audiovisual. Após, não havendo outras

provas a serem produzidas, declarou o MM. Juiz o encerramento da instrução, e, então, determinou que se passasse às alegações finais orais, gravadas pelo sistema audiovisual, iniciando-se com o Ministério Público, e na sequência, o Defensor do réu. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença. "VISTOS. RODRIGO ELIAS BARBOZA, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 16hs, na Estrada Municipal situada entre Mirassol e o Distrito de Ruilândia, zona rural deste Município e Comarca, trazia consigo 31 (trinta e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 7,13 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico ilícito. A denúncia foi recebida no dia 15 de agosto de 2022. O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Houve audiência de instrução e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Em primeiro lugar transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa". A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.01), pelos Termos de Depoimentos (fls.02, 03), pelo Auto de Interrogatório (fls.04), pela Nota de Culpa (fls.06), pelo Boletim de Ocorrência (fls.34/36), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.39/40), pelas fotografias (fls.50), pelo ofício de encaminhamento de preso (fls.49), pelo Laudo Pericial (fls.42/44, 98/100, 197/205), pelo Relatório Final (fls.107/108), bem como pela prova oral produzida. Passo à análise da autoria. O policial militar MARCELO contou na delegacia de polícia que "após denúncia via COPOM de que havia indivíduos vendendo drogas pelas ruas do bairro Bela Vista desta cidade, dirigiu-se com sua equipe ao local, encontrando, na via, um homem que, ao avistar a viatura, passou a andar depressa, andando e olhando para trás. Diante de tal atitude, abordaram tal homem, o qual disse que "tinha um beozinho no bolso", na presença de seu companheiro de farda SALLES, sendo o homem revistado, do que encontraram no bolso de sua bermuda um pequeno saco transparente contendo vários pinos de cocaína. Deram voz de prisão ao homem, identificado como RODRIGO ELIAS BARBOZA, o qual passou a tentar correr e não deixava ser algemado se debatendo a todo momento sendo necessário uso de força física com técnicas de imobilização para contê-lo e algemá-lo. RODRIGO estava com um celular nas mãos e vinte reais em seu outro bolso, junto ao RG. Em pesquisas nos sistemas policiais, foram encontradas diversas ocorrências envolvendo o autor, inclusive por tráfico. RODRIGO afirmou que mora ali no bairro Bela Vista mesmo e que estava vendendo droga para "levantar um dinheiro". Foram contados 31 eppendorfs aparentando ser cocaína. Devido a estar levemente lesionado, passou pelo UPA para atendimento, sendo liberado e apresentando nesta unidade". Em juízo confirmou seu depoimento, de forma coerente e harmônica. O policial militar RODRIGO na delegacia de polícia confirmou o depoimento de seu colega de farda Marcelo. Em juízo confirmou seu depoimento, de forma coerente e harmônica. A testemunha de defesa MARCELIO, disse em juízo que "sabe que o réu é amigo e trabalhador ". O réu RODRIGO, na delegacia de polícia disse que "mora na cidade de São Paulo, mas mudou-se para Mirassol pois sua ex-mulher morava aqui, da qual separou-se. Não vende droga alguma e não sabe de onde os policiais tiraram a droga que lhe foi atribuída. É usuário de drogas, do tipo cocaína e crack. Nesta data, em torno de 15h, estava voltando de um bar do bairro Bela Vista para sua casa, que era perto, quando viu uma viatura dos "gaep" passando, sendo que nada fez, dando os policiais a volta no quarteirão e lhe olharam, do que ele mesmo foi até a viatura, quando os policiais desceram e revistaram, não achando nada, passando a pedir o celular, que disse que estava em sua casa, então um policial foi a pé até sua casa e voltou com seu celular na mão, mandando "tirar a senha", do que o declarante negou e então foi agredido com soco se chutes e disseram que "então ele a preso", mostrando um pacote transparente de

pinos, algemando-o, quando passou a se revoltar, pois não tinha nada ilegal consigo. Foi trazido para esta Delegacia e aqui teve seu advogado comunicado. Tem passagem criminal por roubo, furto, dois tráficos, e já foi preso". Em Juízo, disse que NÃO é verdadeira a acusação, falou que "os policiais mentem porque o depoente não quis caguetar o esconderijo dos traficantes. Os militares estavam averiguando um JETTA preto. Os policiais não encontraram nada e lhe bateram. Viram que o depoente tinha passagem e começaram a pressioná-lo. O policial SALES foi até a sua casa, sem que ninguém estivesse lá. Um dos policiais tiraram uma porção de drogas do colete e então o depoente começou a gritar que eles iriam 'forjar'". Portanto, diante do que restou apurado, de rigor a procedência da ação penal. O réu negou o crime, mas não apresentou nada que poderia justificar falsa acusação dos policiais contra si. Não soube justificar a guarda do entorpecente, apenas dizendo que não era seu. Já os policiais foram firmes e uníssonos em seus depoimentos. Deram a mesma versão em juízo quando do auto de prisão em flagrante. Não há, ainda, qualquer razão para se duvidar do relato dos agentes públicos, que não teriam motivos para acusar o réu injustamente, sendo seus testemunhos válidos, com o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, sendo inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e quando corroborado com os outros elementos de prova. Os policiais contaram que foram informados de que o havia indivíduos vendendo drogas no bairro Bela Vista, e que ao se dirigirem ao local, avistando o réu, ele teve comportamento suspeito, então o abordaram e encontraram os entorpecentes. O exame químico-toxicológico (fls.98/100) realizado nos entorpecentes encontrados em poder do réu resultou em positivo para COCAÍNA, substância de uso proscrito no Brasil. Observo que a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento demonstra a finalidade diversa do simples uso. Fica afastada, portanto, a tese para uso próprio, sendo irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele. Importante registrar também que é desnecessária a demonstração da comercialização da droga no momento do flagrante para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente. Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo)... não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram à sociedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinadas tipos de drogas". (Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. 2007, Editora Revista dos Tribunais, p. 314/315). Ou seja, é punida a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, portanto, não há necessidade de efetiva prática do ato de comércio da substância entorpecente com a finalidade de venda. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES DEFENSIVAS: I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. II) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. III) REESTRUTURAÇÃO DA PENA. IV) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu guardava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico. 2. As provas produzidas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo como acolher a pretendida desclassificação da conduta para a de uso próprio. 3. O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública, não se restringindo à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. 4. Inviável o acolhimento da pretendida reestruturação da pena, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que já fixada no patamar mínimo legal, após análise esmerada de cada um dos moduladores descritos no art. 59, do CP. 5. Impossível prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, eis que o

acusado, na fase policial, silenciou-se e, em juízo, apesar de admitir que a droga era de sua propriedade, alegou que seria destinada ao uso e não ao tráfico, crime este pelo qual restou condenado... O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Esse delito não se restringe à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade. Daí porque não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.”. (Apelação Criminal 1.0480.11.006978-2/001; 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR WALTER LUIZ DE MELO; j. 28/08/2012). Ainda: “TÓXICOS - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A SUA APLICAÇÃO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CPB - CABIMENTO NO CASO CONCRETO. - Se, apesar de o réu negar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as provas são aptas a comprovar os fatos havidos na denúncia, correta é a condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. - A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para tornar a conduta atípica, uma vez que o delito de tráfico, enquanto delito de perigo abstrato, apresenta grande lesividade à saúde e à incolumidade pública, o que não pode ser graduado somente pela quantidade de entorpecente apreendida. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. - A fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, deve ser fixada de acordo com as regras do art. 59 do CPB daquela norma antidrogas. - Adotando o novo entendimento disposto quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cabível é a concessão do regime prisional diverso do fechado nos casos de tráfico privilegiado. - Preenchidos os requisitos legais, cabe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo no caso de tráfico de entorpecentes.”. (Apelação criminal nº 1.0079.10.610239-9/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR CATTÁ PRETA, j. 04/09/2012). Diante de todo o exposto, considero que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa. Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas, verifico que o réu possui maus antecedentes (fls.157/159), assim aumento a pena em 1/6 para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Fls. 145/159 – Processo 0002311-35.2015.8.26.0358), pelo que aumento a pena em 1/6, para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na terceira fase, impossível aplicar a redutora do §4º do art. 33 da lei de drogas, pela reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que torno a pena acima definitiva. O regime carcerário será inicialmente o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando também a reincidência. Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução. O réu não tem direito a benefícios que substituem a pena privativa de liberdade, principalmente por não preencher os requisitos subjetivos do artigo 44, e do artigo 77, ambos do Código Penal. Além disso, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06: “Os crimes

previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos". Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa do ofendido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e assim CONDENO o réu RODRIGO ELIAS BARBOZA, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial FECHADO. A pena de multa deverá ser calculada no mínimo legal, conforme fundamentação acima, a ser atualizada pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, § 2º do Código Penal. A prisão cautelar do réu deve ser mantida. A quantidade de entorpecentes apreendida em sua posse demonstra que seria impossível ficar em liberdade sem prejudicar a ordem pública, sendo reincidente específico. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido às folhas 39 (R\$20,00) por ser produto do ato equivalente ao crime de tráfico. Transfira-se a SENAD com as cautelas de praxe. Determino a destruição do celular, (fls.39), nos termos do artigo 516, § 2º, NSCGJ. Por fim, quanto ao entorpecente apreendido (fls.39/40), o Juízo do Plantão Judiciário já determinou sua incineração (fls.70) nos termos do Provimento CG 45/2018 e do artigo 524-A NSCGJ, já cumprido conforme fls.94/97. Custas "ex lege". Ao defensor nomeado, arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça-se certidão. P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Após a prolação da sentença foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer, sendo manifestado pelo defensor do acusado o interesse na apresentação de recurso de apelação. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, e concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões de apelação. Em seguida abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo. Pelo Dr. Promotor dito de forma expressa e verbal: renuncio ao direito de recorrer. Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: homologo a renúncia da acusação. O Trânsito em Julgado ocorreu nesta data para o Ministério Público. NADA MAIS. A seguir foi a presente encerrada. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelo MM. Juiz e dispensada assinatura das demais partes. Eu, Daniele Rodrigues Piovan, digitei. ADVERTÊNCIA: A audiência foi realizada pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. As partes poderão ter contato com o registro das gravações sem necessidade de transcrição. A gravação da audiência poderá ser visualizada no Portal e- SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo. O juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim.